

1500427-69.2021.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

1500427-69.2021.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500427-69.2021.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCELO HENRIQUE RIBEIRO

Juiz de Direito: Dr. VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra MARCELO HENRIQUE RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos (fls. 22/25), imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 329, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Narra a inicial acusatória que, no dia 23 de julho de 2021, por volta de 22h, no cruzamento da Avenida Orestes da Costa Sene Jr com a Rua Fortaleza, nesta cidade e comarca de Itápolis/SP, o denunciado foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, para venda clandestina, 62,94 gramas de "Cannabis Sativa, L"., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 13 (treze) invólucros plásticos, bem como 19,2 gramas de cocaína, na forma de crack, acondicionada em 31 (trinta e um) invólucros, substâncias que causam dependência física e psíquica (vide laudos de exame químico-toxicológicos de fls.84/89), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, mesma ocasião em que opôs-se à execução de ordem legal consistente em prisão em flagrante, mediante violência aos policiais militares PEDRO PAULO RODRIGUES e WILSON ROBERTO FURLAN, funcionários competentes para executá-lo (fls. 96/98). O réu foi devidamente notificado, apresentando resposta escrita às fls. 104/112. Denúncia recebida em 9 de novembro de 2021, conforme decisão de fl. 126/136.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação e 04 (quatro) testemunhas arroladas pela defesa, sendo, em seguida, interrogado o acusado. Após, o representante do Ministério Público e o defensor apresentaram alegações finais orais.

Os autos me vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Antes de proceder à análise do mérito, verifico que a defesa arguiu a preliminar de inépcia da denúncia, devendo a inicial ser rejeitada ou o réu ser absolvido sumariamente.

Não há como acolher o pleito defensivo.

Ao contrário do alegado pelo(a) defensor(a), a inicial acusatória narrou de forma escoreita o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, contendo, ainda, a qualificação do réu, a classificação do crime e o rol de testemunhas, possibilitando, assim, ao denunciado exercer a ampla defesa. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, não há que se falar em rejeição da exordial.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprido ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do(a) agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do(a) autor(a) do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o(a) denunciado(a) explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e) a circunstância de o(a) acusado(a) ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar

sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o(a) autor(a) do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele(ela) traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo auto de exibição, apreensão, constatação (fl.13/15), pelo auto de avaliação, pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12 e 79/80), pelos documentos fotográficos (fls. 19/21 e 81/82), pelo laudo pericial de entorpecentes (fls. 84/89), pelo relatório de inquérito policial (fls. 87/89) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Com efeito, restou demonstrado que no dia 23 de julho de 2021, por volta de 22h, no cruzamento da avenida Orestes da Costa Sene Jr com a rua Fortaleza, nesta cidade e comarca de Itápolis/SP, o denunciado MARCELO HENRIQUE RIBEIRO foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, para venda clandestina, 62,94 gramas de maconha, acondicionada em 13 (treze) invólucros plásticos, bem como 19,2 gramas de cocaína, na forma de crack, acondicionada em 31 (trinta e um) invólucros, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Os elementos de prova dos autos também evidenciaram que, na mesma ocasião, o acusado MARCELO HENRIQUE RIBEIRO se opôs à execução de ordem legal, consistente em prisão em flagrante, mediante violência aos policiais militares PEDRO PAULO RODRIGUES e WILSON ROBERTO FURLAN, funcionários competentes para executá-lo. Conforme narrado na denúncia, policiais militares em patrulhamento de rotina foram acionados para o atendimento de uma ocorrência de averiguação de tráfico de drogas no local supracitado. A denúncia informava que vários indivíduos haviam ateado fogo em madeiras no meio da rua e estariam com pedaços de madeiras em mãos, intimidando os transeuntes que passavam próximo ao local, conhecido como ponto de tráfico. Ademais, tais indivíduos estariam fazendo "selfie" com drogas nas mãos.

Ao chegarem ao local, os policiais viram um grupo de homens e algumas mulheres com pedaços de madeira em mãos, dentre eles o denunciado MARCELO HENRIQUE RIBEIRO. Os agentes públicos deram ordem de parada para que tais pessoas fossem abordadas, entretanto o denunciado MARCELO se opôs à referida ordem, sendo necessário o uso de força física e bastão "tonfa" para desarmá-lo, tendo em vista que o denunciado, munido de um pedaço de madeira, investiu contra os policiais.

Em busca pessoal, os policiais encontraram na posse de MARCELO, em sua cintura, e presas à bermuda, porções de cocaína e de maconha, além da quantia de R\$ 70,00 (setenta reais) em espécie.

Vejamos.

O acusado MARCELO HENRIQUE RIBEIRO, ao ser interrogado na fase policial, negou a autoria delitiva. "Nega que a droga lhe pertença. Esclarece que nada de ilícito fora encontrado consigo e inclusive não usava cueca, portanto não estava com droga oculta em sua bermuda" (sic) (fls. 08 - grifo meu).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado MARCELO HENRIQUE RIBEIRO negou a autoria. Sustentou que no dia dos fatos saiu para comprar marmita. Sua esposa BIANCA ficou usando wifi na esquina. Quando o interrogado voltou, a polícia estava abordando todos, inclusive sua esposa. Ao ver sua esposa sendo abordada, o interrogado se apossou de um pedaço de madeira, momento em que um dos policiais apontou uma arma de fogo em sua direção. O interrogado então decidiu sair do local, porém foi agredido e algemado pelos policiais, bem como foi colocado dentro de uma viatura policial. Dentro da viatura já havia outro rapaz, de nome JOSÉ HENRIQUE. O interrogado não estava com drogas na sua cintura. JOSÉ HENRIQUE assumiu a propriedade dos entorpecentes na Delegacia de Polícia de Ibitinga/SP.

As testemunhas WILSON ROBERTO FURLAN e PEDRO PAULO RODRIGUES, policiais militares, arroladas pela acusação, em solo policial, disseram que estavam em patrulhamento de rotina, "quando foram acionados via CAD/190 para o atendimento de ocorrência de averiguação de tráfico de drogas pela Av. Orestes da Costa Sene Jr x rua Fortaleza.

A denúncia informava que vários indivíduos haviam ateado fogo em madeiras no meio da rua e estariam com pedaços de madeiras em mãos, intimidando os transeuntes que passavam próximo ao local, suposto ponto de tráfico. Segundo referida denúncia, os indivíduos faziam selfie com drogas na mão. Com apoio da vtr i-13228 "cgp" sgt pm MATHEUS e soldado, policial militar RICARDO e viatura i-13229 "dejem" cabo policial militar FELIPE e soldado policial militar BELANDA deslocaram-se para o referido local. Chegando lá avistaram um grupo de homens e algumas mulheres com pedaços de madeira em mãos. Foi dado ordem de parada e verbalizado para que os indivíduos se postassem em posição de abordagem, entretanto tal ordem foi desobedecida, sendo necessário o uso de força física e bastão tonfa para desarmar MARCELO e JOSÉ HENRIQUE. Foi necessário algemá-los, pois eles estavam em posse de pedaços de madeiras e investiam contra as equipes. Ato contínuo foi realizada busca pessoal nos indivíduos, sendo que com MARCELO foi localizado em sua cintura, preso à bermuda, 31 (trinta e uma) porções de cocaína e 13 (treze) porções de maconha, além da quantia em dinheiro no valor de R\$ 70,00 (setenta reais). Com JOSÉ HENRIQUE nada foi de irregular foi localizado. Entretanto, ao questionarem MARCELO acerca das drogas apreendidas consigo ele negou que o entorpecente fosse de sua propriedade. JOSÉ HENRIQUE, por sua vez, declarou que a droga que MARCELO carregava lhe pertencia. Os Militares acreditam que MARCELO convenceu JOSÉ HENRIQUE a dizer que a droga era sua porque este completou a maioridade recentemente e teria mais chances de conseguir liberdade provisória na audiência de custódia. Durante o trajeto até a Delegacia de Polícia, MARCELO ficou dizendo que era integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital- PCC. Outras pessoas armadas com pedaços de madeira também investiram contra as equipes policiais, sendo necessário uso de bastão tonfa para dispersá-los, não sendo possível realizar a abordagem de todos. Diante dos fatos ambos foram detidos e algemados, para prevenir eventual tentativa de fuga bem como para proteger a integridade física tanto dos detidos quanto dos Policiais. Foram conduzidos ao Pronto Socorro da Santa Casa onde passaram por exame de corpo de delito. Foram atendidos pelo dr. PABLO CRM 316242 e posteriormente trazidos a este Plantão Policial de Ibitinga para as providências de Polícia Judiciária pertinentes" (sic) (fls. 03/07)

Ao serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas WILSON ROBERTO FURLAN e PEDRO PAULO RODRIGUES, ratificaram seus depoimentos anteriores. Acrescentaram que, na data dos fatos, foram informados via 190 de que na esquina da Av. Oreste Costa Sene Júnior com a Rua Fortaleza, local conhecido como ponto de venda de drogas, indivíduos teriam ateado fogo em pedaços de madeira na via pública, bem como estariam armados com pedaços de madeira, intimidando os transeuntes. Ainda segundo a denúncia recebida, tais indivíduos estariam tirando "selfies" com drogas. Os depoentes se deslocaram até o local e avistaram várias pessoas com pedaços de pau em mãos, bem como avistaram madeira sendo queimada na via pública. Foi dado ordem de parada e verbalizado para que os indivíduos se postassem em posição de abordagem, porém a ordem foi desobedecida pelo acusado MARCELO HENRIQUE RIBEIRO, por JOSÉ HENRIQUE CORREA e por outros indivíduos. MARCELO investiu contra a equipe policial portando um pedaço de madeira e teve que ser contido, desarmado e algemado. Em poder de MARCELO os depoentes apreenderam R\$ 70,00 (setenta reais) em espécie e, em sua cintura, 31 porções de cocaína e 13 porções de maconha enroladas em papel filme de PVC. O acusado MARCELO negou a propriedade dos entorpecentes, que foi assumida por JOSÉ HENRIQUE, sendo, em seguida, dado voz de prisão a ambos. MARCELO e JOSÉ HENRIQUE costumavam frequentar o local, que é conhecido como ponto de venda de drogas. Além disso, ambos são conhecidos nos meios policiais como traficantes de entorpecentes. Quando estava na viatura de polícia, MARCELO disse ser integrante da facção criminosa PCC. MARCELO já havia sido preso por tráfico de drogas em 2018 e está respondendo por outro processo referente a porte de drogas. Por sua vez, JOSÉ HENRIQUE, que à época dos fatos havia acabado de completar a maioridade, ostentava vários atos infracionais. As drogas estavam com MARCELO, entre o seu corpo e a bermuda. Não se recorda se foram apreendidos celulares. Aproximadamente 8 pessoas estavam armadas com pedaços de madeira.

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha GUILHERME HENRIQUE RUIVO, arrolada pela

defesa, narrou que estava no local dos fatos a aproximadamente um quarteirão de distância. Os policiais agrediram fisicamente MARCELO sem qualquer motivo, bem como ofenderam a namorada dele. As pessoas que estavam lá fizeram uma fogueira porque estava frio. MARCELO não agrediu os policiais.

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha BRUNA EDUARDA ANDREOTTI, arrolada pela defesa, narrou que é cunhada de MARCELO. No dia dos fatos, estava na esquina em frente ao local da prisão. Os policiais agrediram BIANCA, namorada de MARCELO, que pegou um pedaço de pau para coloca-lo na fogueira. Um policial apontou um revólver na direção de MARCELO, que foi agredido e algemado pelos policiais, sendo em seguida colocado na viatura.

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha BIANCA CAMILE ANDREOTTI, arrolada pela defesa, narrou que é esposa de MARCELO. Narrou que, no dia dos fatos, estavam fazendo uma fogueira, pois estava fazendo frio. MARCELO pegou um pedaço de madeira para colocar na fogueira. A depoente ofendeu os policiais e eles a agrediram. MARCELO ficou revoltado e estava com um pedaço de madeira. Um dos policiais apontou uma arma de fogo na direção de MARCELO, que deixou o local. Em seguida, MARCELO foi agredido e algemado pelos policiais, bem como foi colocado em uma viatura. MARCELO não estava com drogas. Não sabe quem estava na viatura além de MARCELO. Não conhece JOSÉ HENRIQUE CORREA. Não registraram as agressões dos policiais com filmagens ou fotografias.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a(s) testemunha(s) do fato, sentindo-se amedrontada(s) e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco(s) detalhe(s) a respeito da empreitada criminosa ou, simplesmente, por mentir à autoridade policial e/ou ao(à) magistrado(a). Em tal contexto, a(s) denúncia(s) anônima(s) e o(s) depoimento(s) de policiais civis e militares possuem grande valor probatório.

5. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do(a) acusado(a).

6. A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 2º, do artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Tóxicos não exige que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia para que sua conduta seja enquadrada no tipo penal do artigo 33, caput. Isso porque o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas").

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, "para alicerçar a pretendida condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer

praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública” (TJSP; Apelação Criminal 1500705-48.2018.8.26.0274; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 - grifo meu).

Ademais, a condição de usuário ou dependente de drogas não é incompatível com a figura do traficante, tampouco afasta per si a imputabilidade do agente. Nesse sentido: TJMS, HC 01733320620158110000, Relator: Desembargador Gilberto Giralde, DJ 04/02/2016; TJDF, APR 0015443-41.2008.807.0001, Relator: Desembargador Souza e Ávila, DJ 03/02/2010.

In casu, a quantidade de entorpecentes apreendida (62,4 gramas de maconha e 19,2 gramas de cocaína, na forma de crack) e sua forma de acondicionamento (em diversas porções, que facilitam o transporte e comercialização) revelam a intenção do denunciado de praticar a traficância ilícita.

Com efeito, conforme se extrai de julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: a) um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5g a 1,0g do entorpecente; b) uma “fileira” de cocaína é confeccionada com 0,1g a 0,125g da droga, aproximadamente; c) uma pedra de crack tem, em média, 0,2g a 0,25g.

Confira-se: Apelação Criminal 1500949-81.2019.8.26.0228; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019; Apelação Criminal 0000617-39.2016.8.26.0247; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018; Apelação Criminal 0000244-11.2015.8.26.0613; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016.

Com base nesses dados, conclui-se que a quantidade de droga apreendida (62,4 gramas de maconha e 19,2 gramas de cocaína, na forma de crack) seria suficiente para produzir diversas porções individualizadas, ou seja, era destinada a entrega a consumo de terceiros.

Cabe ainda ressaltar que, embora o réu não tenha sido flagrado comercializando drogas, há nos autos elementos indicativos de que ele estava praticando o tráfico de drogas, entre os quais: a) a existência de denúncia anônima relatando que indivíduos, entre os quais o acusado, estavam em local conhecido como ponto de venda de drogas (esquina da Av. Orestes da Costa Sene Júnior com Rua Fortaleza) fazendo selfies com drogas; b) o acusado é conhecido nos meios policiais como traficante de drogas, sendo, inclusive, reincidente específico (processo n.º 0000002-94.2018.8.26.0274).

7. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

In casu, verifico que o acusado é reincidente específico: processo n.º 0000002-94.2018.8.26.0274, bem como ostenta uma condenação criminal não definitiva por crime de tráfico de drogas: processo n.º 0002191-50.2015.8.26.0274.

Ademais, de acordo com os policiais militares, o acusado já é conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de entorpecentes, tendo sido abordado por milicianos em ponto de venda de entorpecentes.

II.3 - Da dosimetria das penas

II.3.1. Crime do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios

da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

No caso dos autos, nenhuma das 8 (oito) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) pode ser valorada negativamente.

Isto posto, estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Reconheço a agravante da reincidência (processo n.º 0000002-94.2018.8.26.0274), razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, e estabeleço a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de

diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 - grifo meu).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II-3.2. Crime do artigo 329, caput, do Código Penal

1. Circunstâncias judiciais

No caso dos autos, nenhuma das 8 (oito) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) pode ser valorada negativamente.

Isto posto, estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 2 meses de detenção.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Reconheço a agravante da reincidência (processo n.º 0000002-94.2018.8.26.0274), razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, e estabeleço a pena intermediária em 2 meses e 10 dias de detenção.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em

primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 398 - grifo meu). Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 2 meses e 10 dias de detenção.

II-3.3. Do concurso de crimes

Considerando que o agente, mediante mais de uma ação, praticou 2 delitos, reconheço o concurso material entre o crime de tráfico de drogas (5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa) e o crime de resistência (2 meses e 10 dias de detenção), razão pela qual, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, aplico cumulativamente as penas, fixando-as em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa e 2 meses e 10 dias de detenção. Deverá ser executada em primeiro lugar a pena de reclusão, nos termos do § 2º, do artigo 69, do CP.

II-3.4. Outras disposições

1. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado para a pena privativa de liberdade de reclusão (crime de tráfico de drogas), com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime semiaberto, a reincidência específica indica que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente. Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto para a pena privativa de liberdade de detenção (crime de resistência), com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime aberto, a reincidência indica que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

2. Substituição por penas restritivas de direitos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto, seja em razão da quantidade de pena aplicada, seja em razão da reincidência, circunstâncias indicativas de que, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

3. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto não se acham presentes os requisitos legais. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268,SP).

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o(a) acusado(a) MARCELO HENRIQUE RIBEIRO como incurso nas sanções do artigo 33, caput,

da Lei 11.343/2006, e do artigo 329, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal: a) à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e b) à pena privativa de liberdade de 2 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Deverá ser executada em primeiro lugar a pena de reclusão, nos termos do § 2º, do artigo 69, do CP.

2. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a) e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva (decretada em 24/07/2021 e mantida em 09/11/2021 e 07/02/2022), que continua necessária para garantia da ordem pública. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: "HABEAS CORPUS - Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - [...] Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada [...]". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262474-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020 - grifo meu).

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final. Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir prejuízo material constatado.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88;

Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado.

Demonstrado que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, decreto seu perdimento em favor da União Federal, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itapolis, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA